

1500875-37.2022.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500875-37.2022.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500875-37.2022.8.26.0320

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2086145/2022 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 23938268 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

871/22/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2086145 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 871/22/923 -

DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

YURI GABRIEL CANDIDO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

YURI GABRIEL CANDIDO DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, no artigo 329, caput, do Código Penal.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 29 de março de 2022, por volta das 10h20min, na Avenida Frei das Mercês, nº 01, Parque Nossa Senhora das Dores I, na cidade e comarca de Limeira, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, 240 porções de "cannabis sativa L", pesando no total 773 g, e 169 porções de cocaína, na forma de "crack", pesando no total 39,68 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo químico-toxicológico definitivo.

Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e local supracitadas, o denunciado se opôs à execução de ato legal, mediante violência e grave ameaça a funcionários públicos (guardas municipais) competentes para executá-lo.

Segundo se apurou, na data dos fatos, o denunciado se encontrava na via pública com entorpecentes, para fins de tráfico.

Guardas municipais, durante patrulhamento no bairro Nossa Sra. das Dores, receberam informação de que um rapaz chamado Yuri estaria de bicicleta e camiseta preta distribuindo entorpecentes na avenida Frei João das Mercês, naquele mesmo bairro, em uma "academia ao ar livre" localizada no canteiro central daquela via.

Desta forma, os agentes públicos para lá se deslocaram, onde avistaram o denunciado e outros dois indivíduos, sendo que um deles estava de bicicleta e trajava camiseta preta. Em seguida, ao notarem a presença da viatura, tais indivíduos saíram correndo e YURI dispensou ao solo uma sacola preta que ele trazia consigo.

Na sequência, o guarda municipal Carlos saiu no encalço do denunciado, que, em determinado momento, deixou a bicicleta e continuou a fuga entrando em uma residência, subindo no seu telhado e passando por outras casas até ser surpreendido pelo agente público quando saía de um imóvel. Entretanto, ao notar que seria abordado, YURI investiu contra o guarda e eles entraram em luta corporal.

Neste momento, os outros dois indivíduos que estavam com o denunciado na praça também agrediram Carlos, na tentativa de livrar o denunciado, mas como não conseguiram, deixaram o local. Em seguida, YURI foi abordado e revistado, sendo encontrada uma porção de maconha no bolso de sua bermuda.

O denunciado foi preso em flagrante e, ao ser colocado na viatura, passou a chutar o compartimento de presos e bateu a cabeça no revestimento plástico, ocasião em que ameaçou o guarda municipal Edson, dizendo: "quando eu sair da cadeia, vou cobrar de você, estou autorizado pelo PCC a te cobrar".

A sacola dispensada pelo denunciado foi recuperada e no seu interior foram encontradas 239 porções de maconha e 169 porções de cocaína, na forma de "crack".

Oferecida à denúncia, determinou-se a notificação do réu para que apresentasse defesa preliminar, que veio aos autos (fls. 160/162).

A denúncia foi recebida em 05 de julho de 2022 (fls. 163/164).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas, com interrogatório do acusado ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se.

Memoriais escritos do Ministério Público (fls. 198/203) e da Defesa (fls. 208/215).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 04), auto de exibição e apreensão (fls. 24/25), boletim de ocorrência (fls. 20/23), laudo pericial com resultado positivo para "cocaína e maconha" (fls. 33/35 e

78/80), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Em Juízo, o acusado disse que tem 19 anos. Estava desempregado. Terminou o terceiro colegial. Na manhã do dia dos fatos, acordou logo cedo, tomou café e pegou uma "seda" que estava no quarto. Tinha dez reais. Foi comprar uma bucha de maconha na posse da bicicleta. Não tinha ninguém na biqueira. Ficou na pracinha. Perguntou para os meninos se tinha alguém lá. Esperou mais vinte minutos. Voltou mais uma vez e pegou a bucha com um moleque. Voltava em poder da droga. Quando chegou perto da padaria passou um Fiat Uno dizendo que era polícia. Uma viatura da ROMU também surgiu. Não entendeu o que estava acontecendo. A viatura da ROMU deixou um rapaz para trás. O guarda disse que ele perdeu. Desceu correndo a avenida. Subiu a rua detrás da avenida com a sua bicicleta. Quando o Fiat Uno chegou, saiu da bicicleta e começou a correr. Iria na direção da sua casa. Pulou na casa de uma pessoa conhecida e pediu ajuda a ela. A pessoa disse que não iria ajuda-lo. Pulou na casa do funileiro e deitou na escada. Os policiais ingressaram na casa. Foi abordado e detido. Queria saber o que estava acontecendo. Os policiais disseram que ele perdeu. Tomou um soco no rosto de um policial, o outro guarda deu rasteira nele. Foi algemado e jogado dentro do camburão. Passou a gritar. Uma sacola preta foi mostrada. Sua prisão foi forjada. Só conhecia o guarda civil municipal Edson, já havia sido abordado uma vez por ele. Não é traficante, mas apenas usuário de maconha. Tinha uma bucha no bolso e uma seda no outro. Pagou dez reais pela bucha. Costumava ir naquela biqueira. Não tem ideia de onde surgiu a sacola apresentada pelos guardas. Acredita que a sacola era do rapaz que estava na biqueira. Não resistiu à ação policial e não agrediu os guardas. Quando era adolescente, teve passagens na Fundação Casa por tráfico de drogas, já chegou a ficar internado. Seu pai já tirou cadeia. Não sabe quantos processos respondeu quando era menor de idade, foram três processos por tráfico e por duas vezes ficou internado. Havia muitas viaturas, até motocicleta apareceu no dia da prisão (mídia).

Vejamos o teor da prova oral, contrária aos interesses do acusado.

O guarda municipal Carlos Donizeti da Silva disse que o tráfico é muito forte na região. A população vem reclamando da traficância. Receberam informação de que o rapaz de camiseta preta e de bicicleta seria o responsável pela venda de drogas naquele local. Diante dessas informações, fizeram patrulhamento. Viram três pessoas de bicicleta, mas só um deles batia com a informação, o nome da pessoa foi repassado. Ao ver a viatura, houve fuga e dispensa de uma sacola por parte do acusado. Fizeram acompanhamento. O réu entrou na feira livre e o seu colega Edson foi no encalço dele. Três quarteirões depois o réu acessou o telhado de uma casa. Seu colega continuou atrás dele e ele deu a volta. Estava em poder de uma cadela dentro da viatura. Deu ordem legal, mas o réu não acatou e partiu para cima dele. Entraram em luta corporal. Os outros dois indivíduos que estavam com o acusado tentaram salvar o denunciado. Depois de muita resistência, efetuou a prisão. Os demais parceiros do acusado fugiram. Havia denúncia de um automóvel abandonado em que o réu retirava as drogas. O acusado os xingava, batia na viatura e proferiu diversos desacatos. Ele dizia que era membro do PCC e iria matar os guardas. Recolheram a sacola e havia 239 porções de maconha e 169 pedras de crack. A venda do dia começaria a ser realizada e foi nessa hora que fizeram a detenção. Viu claramente o acusado dispensando a sacola. Ao ver que seria abordado, o réu a dispensou. Não conhecia o denunciado, nunca tinha visto ele. Fizeram três revistas no réu. Viu a entrega de uma "seda" na delegacia por parte de um advogado para corroborar a alegação de usuário, mas nada pode fazer por se tratar de advogado. A informação chegou por populares, a traficância está intensa naquela região. Não machucou o réu. Quem o denunciou é uma pessoa que mora ali perto. O cachorro não teve participação no evento, foi tudo muito rápido. Posteriormente chegou várias viaturas. O acusado estava muito valente e passou a quebrar a viatura. Os dois rapazes que tentaram resgata-lo não entraram em luta corporal. O acusado tem uma

estatura grande. Ele tinha uma bucha em seu poder, não sabe o bolso. Não consegue identificar qual bucha foi encontrada em poder do acusado. No apoio chegaram a viatura do Coimbra e do guarda Paulo, assim como as motocicletas de segurança (mídia).

O guarda civil municipal Edson dos Santos contou que a ocorrência foi complicada. O réu resistiu à ação policial. Há testemunha que o incriminou em razão daquela prisão, mas na Corregedoria da Guarda Civil Municipal foi tudo arquivado. Faziam patrulhamento e sabiam que as drogas naquela região seriam distribuídas. Foram avisados por populares. As características do réu foram repassadas, assim como o nome. Há escolas e asilo na região. No local apontado viram três pessoas. Um deles tinha a característica repassada e soltou uma sacola com drogas assim que viu a viatura, era o réu Yuri. Viu isso nitidamente. Desembarcou da viatura e fez acompanhamento a pé. O réu andava de bicicleta e caçoava deles. O acusado não parou. Yuri entrou atrás de um ônibus e invadiu uma residência. O acusado passou a subir pelo telhado. Seu parceiro conseguiu detê-lo na outra parte. Ele já estava algemado. Seu parceiro informou que os dois indivíduos que fugiram tentaram resgatar o réu. Colocaram Yuri na viatura. A informação era que o acusado pegava drogas em um automóvel Monza. O réu se debateu na viatura, passou a xinga-los e proferiu ofensas muito fora do comum, eram ameaças muito perigosas, nunca viu aquilo no seu trabalho como guarda municipal. Uma pessoa prestou depoimento mentiroso sob a alegação de que ele o agrediu. Nem chegou a falar com o acusado de tão violento que ele estava. Foram os policiais civis que coletaram os dados pessoais do réu. Com mais de vinte anos de serviço, nunca tinha visto aquilo. Na sacola havia várias porções de drogas. A todo tempo teve resistência verbal e física pelo autuado. Ele dava cabeçadas na sua pessoa. Só conhecia o acusado por nome, não o conhecia pessoalmente. A informação veio por moradores, em datas anteriores já havia sido passado, no dia sabia que haveria distribuição, por isso foram para aquela região, chegou denúncia. O tráfico é muito forte no local. A população ali na região está cansada do tráfico, o pessoal da feira livre está preocupado com a clientela, há asilos e escolas na região e estão cerceados pela criminalidade, ali prevalece a lei do silêncio, mas há populares que confiam no trabalho deles e passavam as informações. O cachorro não desceu para procurar, o cão ficou dentro da viatura porque encontraram a sacola. Não sabe o local exato da dispensa da sacola. Não se recorda o nome da rua que foi dispensado o entorpecente. Pegou a sacola do chão. Diversas viaturas deram apoio, a ação do réu foi muito agressiva. Tiveram apoio de um superior na ocorrência. Encontraram uma porção de maconha em poder do réu. Geralmente é entregue separadamente as drogas, mas não se recorda ao certo o destino na delegacia. Não se recorda o peso da droga que foi encontrada em poder do réu. Na abordagem ninguém teve contato pessoal, salvo os guardas civis. Fizeram revista mais minuciosa. A viatura de canil é especializada em tráfico de drogas. Em vinte anos nunca repassou por uma situação dessa, foi investigado pela Polícia Civil e pela Guarda Civil Municipal, sendo arquivada a investigação (mídia).

Quanto à ação dos guardas municipais, tem-se que perfeitamente válida. É cediço que o artigo 144, § 8º, da Constituição Federal estabelece que a guarda municipal será destinada apenas à proteção de bens, instalações e serviços dos Municípios, não tendo ela, portanto, a função de garantir a segurança, bem como investigar a prática de crimes. No entanto, referida limitação não significa que a guarda municipal não possa prender em flagrante quem estiver cometendo um delito.

“(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o

exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP – Rel. Min. Moura Ribeiro – j. 27.05.14; RHC 45.173/SP – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 26.05.14 e HC 109.105/SP – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima – j. 23.02.10) (...)" (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

Foram ouvidas testemunhas de defesa.

A testemunha Tâmara Raquel Agus disse que conhece o acusado de vista. Estava no barracão. Viu o acusado na avenida, ele estava indo na biqueira comprar maconha. O réu voltou porque não tinha ninguém lá. Depois viu ele correndo. Uma pessoa gritou para o réu. Correu atrás para ver o que ocorria, agiu como curiosa. Não viu o acusado pulando o muro. Ele estava no chão quando foi abordado pelos guardas. Não viu pessoas tentando resgatar o réu. Um monte de viatura chegou. O denunciado proferia xingamentos e dizia que estavam forjando a prisão dele. Não sabe o local do encontro de drogas. Foi na delegacia fazer a denúncia e não sabe o desfecho. Sua amiga Jéssica pediu para o réu comprar maconha, mas ele disse que não tinha alguém lá. Havia um carro Uno e a pessoa gritando muito, a pessoa disse ser da polícia (mídia).

A testemunha Paulo Sérgio Campo contou que conhece a família do réu. Não é de ficar na rua. Quando saiu no portão, o circo estava formado. O acusado já estava no interior da viatura. Uma pessoa disse que a droga não era do réu, ele não era culpado, mas não conhece essa pessoa. Não viu a abordagem policial (mídia).

A testemunha Amanda de Oliveira Souza disse que o acusado é seu primo. Foi ouvida como informante. Sua prima ligou avisando que seu tio estava passando mal. O réu já estava dentro da viatura. Foi acionado a ir até lá. O acusado não gritava. Ouviu uns meninos falando que ele não era dono das drogas. Sabe que seu primo fuma maconha. Os familiares queriam interna-lo (mídia).

A testemunha Maria Sueli de Souza contou que é tia do acusado. Foi ouvida como informante. Não estava no dia dos fatos, não presenciou a abordagem. Foi na delegacia. Pode dizer que o acusado é boa pessoa. Não sabia que ele vendia algo, sabe que ele fazia uso de maconha. Sua irmã e ela tentaram arrumar uma clínica para ele sair dessa vida. O réu havia perdido o genitor em dezembro. Sabe que o acusado tem dezoito anos e não é pessoa perigosa, é uma pessoa calma e todos gostam dele (mídia).

A testemunha Mariana Pinto da Silva disse que é tia do réu. Foi ouvida como informante. Estava em casa cuidando dos afazeres e escutou alguém gritando pela tia do réu. A informação era que a polícia corria atrás dele. Nisso saiu correndo. A informação é que batiam no réu. Havia um monte de viatura policial. Viu o seu sobrinho no camburão. Os guardas não deixaram conversar com o acusado. Seu sobrinho não tem envolvimento com o tráfico, ele apenas faz uso de drogas (mídia).

Passo analisar os delitos separadamente.

Artigo 33, caput, da Lei de Drogas.

Pelo teor da prova oral colhida, o denunciado estava na via pública efetuando o comércio de drogas, quando guardas civis municipais, em patrulhamento rotineiro e na posse de informações do acusado (denúncia anônima), viram a pessoa indicada como traficante. Ao notar a presença da viatura, houve correria e o réu dispensou uma sacola que trazia consigo.

Iniciou-se uma perseguição e fuga pela região. Houve luta corporal entre um dos guardas e o acusado. Após ser detido, foi efetuada revista pessoal e localizada uma porção de maconha. Na sacola dispensada foram localizadas 239 porções de maconha e 169 de "crack".

Ao ser colocado na viatura, o acusado passou a proferir ofensas pesadas contra os guardas, sob a alegação de ser integrante de conhecida facção criminosa.

Desse modo, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico imputado, haja vista a quantidade, a natureza e a forma como estavam embaladas as drogas (cocaína e maconha) a conduta do acusado quando da sua prisão e o depoimento incriminador dos guardas civis, tudo a apontar o réu como pessoa envolvida no tráfico de drogas.

Sobre o tema em comento, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo é remansosa:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 - Absolvição ou, ainda, desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas - Descabimento - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Palavra dos policiais militares - Credibilidade - Precedentes - Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão - Ausência de visualização de atos de mercancia - Irrelevância - Tipo misto ou de conteúdo variado - Condenação mantida (...)" (TJSP; Apelação 0004568-50.2015.8.26.0126; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro: 11/10/2017).

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) Materialidade e autoria delitiva comprovadas, sobretudo diante dos relatos seguros dos policiais militares que participaram da diligência. Escusa ofertada pelo réu isolada no quadro probatório. Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Condenação mantida (...)" (TJSP; Apelação 0000137-25.2017.8.26.0571; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 01/03/2018).

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADA, EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO, INCONSISTENTE A

NEGATIVA DE AUTORIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOCAL DA ABORDAGEM, CONHECIDO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES, MODO COMO OS ESTUPEFACIENTES ESTAVAM EMBALADOS, QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA COMPATÍVEIS COM O TRÁFICO(...) (TJSP; Apelação 0002975-45.2014.8.26.0344; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 9ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Marília - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/09/2017; Data de Registro: 26/09/2017).

Segundo entendimento do saudoso Luiz Flávio Gomes:

“Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)” (GOMES, Luiz Flávio e CUNHA. Rogério Sanches (Coordenadores). Legislação Criminal Especial. Volume 6. São Paulo: Editora RT, 2009).

Não há que se falar em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, principalmente em razão da quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, assim como as circunstâncias da prisão em flagrante, existindo depoimento incriminador dos guardas civis municipais envolvendo o acusado.

Na esteira dos ensinamentos de Cleber Masson:

“Os critérios mencionados devem ser aferidos conjuntamente. Apenas um deles, isoladamente, nem sempre conduzirá o intérprete a adotar a melhor solução. Perceba-se, por curial, que uma quantidade relativamente pequena de droga não indica, necessariamente, que o sujeito ativo a tem para consumo pessoal. Como se sabe, é cada dia mais incomum a existência de grandes depósitos de drogas. Os traficantes, justamente para dificultar a ação repressiva do Estado, têm preferido muitas vezes trabalhar com pequenas quantidades distribuídas entre várias “mulas” (MASSON, Cleber. Lei de Drogas: aspectos penais e processuais. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019).

Não é diferente o posicionamento jurisprudencial:

"Tráfico de entorpecentes – Dolo de traficar – Desclassificação para porte de entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – Descabimento Provado o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabe a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, se for observado que as demais circunstâncias que cercaram a prisão do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes (...)" (TJSP; Apelação 0002093-84.2015.8.26.0300; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jardinópolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 06/03/2018).

“APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Apreensão de porções de "maconha", "crack" e cocaína. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente pretende a desclassificação para consumo pessoal, o reconhecimento da figura privilegiada, o abrandamento do regime prisional, a substituição da carcerária por restritivas de direitos e a inconstitucionalidade da pena de multa. Materialidade e autoria indúvidas. Réu preso em flagrante na posse de entorpecentes, na via pública, após delação anônima feita aos policiais. Quantidade e diversidade denotam a traficância.(...)” (TJSP; Apelação 0005361-26.2016.8.26.0361; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

Note-se, ainda, que o réu nada indicou de real para colocar dúvidas sobre a atuação

dos guardas civis, pois a abordagem foi de rotina, em decorrência do patrulhamento de rotina.

De fato, o depoimento dos agentes públicos em audiência convence. O cotejamento dos depoimentos prestados pelos agentes da lei, nas duas fases procedimentais, demonstrou que seus relatos foram convergentes e coerentes. Seus depoimentos, alinhados com a prova documental e pericial carreada, se mostraram perfeitamente válidos e devem ser acolhidos.

Não convence o teor do depoimento das testemunhas de defesa Tâmara e Paulo. Embora tenham alegado que não viram a dispensa e nem o encontro de drogas, observo que os guardas civis relataram exatamente o contrário, tanto que prenderam o acusado em flagrante delito após a dispensa da sacola.

As testemunhas de defesa não afastam a credibilidade e precisão do que foi narrado pelos agentes públicos em todas as oportunidades em que foram ouvidos. Ademais, o testemunho dos guardas municipais vem corroborado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e laudo pericial (Polícia Civil).

Aliás, no caso de acolhimento da versão do acusado (de que o entorpecente foi "plantado"), seria dada razão a tese de que os agentes públicos, de algum modo, adquiriram as drogas, colocaram os entorpecentes na sacola e, por fim, encenaram uma situação de flagrante delito para efetuar a prisão do acusado após a sua fuga e perseguição.

A mencionada tese, além de inverossímil, carece de substrato fático probatório mínimo que lhe corrobore. Afinal, se o acusado e as testemunhas por ele arroladas não viram o encontro das drogas, também não viram os guardas "plantando" o material no local.

Com o devido respeito ao entendimento da combativa Defesa, após todo o processado, não se extrai qualquer razão lógica e plausível de suposta armação dos guardas municipais para incriminar o acusado, de modo a aponta-lo injustamente como autor do grave crime de tráfico de drogas

Difícil imaginar que guardas civis de Limeira desperdiçariam seu precioso tempo e criariam uma estória fantasiosa para ser trazida à Polícia Civil, Ministério Público e Poder Judiciário, forjando provas e plantando drogas, para acusar o réu, que seria pessoa inocente e sem qualquer envolvimento com a traficância ilícita. É absurda essa situação.

Já se ouviu nos jornais e noticiários que algum agente de segurança pública foi preso ou condenado pelo cometimento de algum delito, o que, à primeira vista, retira a fé daqueles servidores (policiais e guardas) que se empenham no dever constitucional de manter a segurança pública.

Todavia, deve ser levado em consideração que a exceção não é a regra e a grande maioria dos guardas civis municipais são pessoas honradas, de boa-fé, dedicados a combater o crime, com inúmeros sacrifícios pessoais, familiares e com risco de morte.

Portanto, a prova oral acusatória convence e fica acolhida.

E não se exige a existência do efetivo comércio para a configuração do crime do artigo 33, caput, da Lei de Drogas. Basta a guarda, o transporte, o trazer consigo, ou a manutenção em depósito, com a finalidade de distribuição ou de entrega a terceiros para que o crime se consuma.



A lei penal pune a mera finalidade (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de Drogas).

Por se tratar de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que é condenável a simples possibilidade de distribuição, gratuita ou onerosa, do entorpecente.

Em comentários ao artigo 33 da Lei de Drogas, o saudoso Luiz Flávio Gomes preleciona:

“(...) Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (p.ex., expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa (...)” (GOMES, Luiz Flávio et al. Nova Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo: Lei 11.343/06 de 23.08.2006. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006).

É esse o caso dos autos.

Note-se que o acusado não tinha trabalho lícito e formal ao tempo dos fatos que lhe propiciasse a aquisição de toda aquela quantidade de entorpecente.

Dessa forma, a condenação no delito de tráfico é a medida de rigor.

Artigo 329, caput, do Código Penal (delito de resistência).

Quanto ao crime em questão, os guardas civis municipais ouvidos em Juízo esclareceram que, durante a ocorrência, o réu reagiu à ação dos agentes públicos. O evento só não foi pior, porque conseguiram deter a ação criminosa do imputado, algemando-o.

Não há, portanto, qualquer prova que ampare a versão do acusado de que foi vítima de violência policial. Aliás, nem sequer apontou quais motivos os guardas civis teriam para inventar a história, uma vez que cumpriam a devida função pública deles.

Está demonstrado, portanto, que o acusado se opôs à execução de ato legal, mediante violência e grave ameaça.

Conforme já restou decidido:

“Sendo legítima a ordem de prisão dada ao réu pelos policiais, opondo-se a ela, de forma violenta, comete o crime de resistência” (TACRIM-SP – AC – Rel. João Guzzo – RT 433/430).

“Palavras e atitudes de ébrio não caracterizam o crime de desacato. Responderá ele, todavia, por resistência, quando com ato de violência que ponha em perigo a própria integridade física dos agentes da autoridade procure obstar o seu recolhimento à prisão” (TACRIM-SP – AC – Rel. Azevedo Franceschini – RT 368/258).

Tipificou-se o crime de resistência. Não há nenhuma causa excludente da antijuridicidade e culpabilidade. Conforme prova oral colhida, não há dúvidas de que o réu resistiu à ação dos agentes públicos, com a tentativa de fuga da abordagem dos guardas civis.

Registre-se que eventual uso de álcool ou droga não exime a responsabilidade do denunciado, porque voluntária. Recorde-se da advertência feita por Fernando Capez, ao acentuar a seguinte lição:

“A embriaguez não accidental jamais exclui a imputabilidade do agente, seja voluntária, culposa, completa ou incompleta. Isso porque ele, no momento em que ingeria a substância, era livre para decidir se devia ou não fazer. A conduta, mesmo quando praticada em estado de embriaguez completa, originou-se de um ato de livre arbítrio do sujeito, que optou por ingerir a substância quando tinha a possibilidade de não o fazer. A ação foi livre na sua causa, devendo o agente, por essa razão, ser responsabilizado”. (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, v. 1. 23. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 358).

A caracterização do crime de resistência não fica comprometida com a embriaguez voluntária do réu, uma vez que no Direito Penal Brasileiro a embriaguez só exclui a imputabilidade quando é completa e proveniente de caso fortuito ou força maior.

Desse modo, demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria das penas a serem aplicadas.

Art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas)

Concernente ao delito em questão, as circunstâncias judiciais dos artigos 59, do Código Penal, e 42, da Lei nº 11.343/2006, são favoráveis ao réu, devendo a pena-base partir do mínimo legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Segundo entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral (STF, ARE 666334 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-084 DIVULG 05-05-2014 PUBLIC 06-05-2014), fica vedada a utilização da natureza e da quantidade da droga, cumulativamente, para majorar a pena-base, na primeira fase, e, na terceira, para modular a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sob pena de indevido bis in idem.

Não há agravantes. Por outro lado, deixo de aplicar a atenuante da menoridade relativa, pois a pena-base já foi estabelecida no patamar mínimo, observando-se o teor da Súmula nº 231 do Colendo STJ.

Na terceira fase, observo que o réu possui histórico de atos infracionais quando da sua menoridade (fls. 43/44 – Autos nº 1513393-03.2019.8.26.0114, 1513462-35.2019.8.26.0114, 0004638-62.2018.8.26.0320, 0004729-55.2018.8.26.0320, 0019433-44.2016.8.26.0320, 1500801-51.2020.8.26.0320, 1502729-37.2020.8.26.0320 e 1505340-31.2018.8.26.0320), tendo cumprido medidas socioeducativas de internação por atos infracionais equiparados ao crime de tráfico de drogas e contando com passagens pela Vara da Infância e Juventude, fato confirmado pelo próprio acusado quando interrogado judicialmente, o que denota dedicação à atividade criminosa com o encontro de 240 porções de maconha, pesando 773 gramas, e 169 porções de cocaína, na forma de “crack”, pesando no total 39,68 gramas, não sendo caso de incidência do redutor previsto em lei, na linha da jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2. Os atos infracionais também podem ser

considerados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa e, portanto, podem ser utilizados para justificar o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo regimental provido. (STJ, AgRg no RESp 1873094/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...). IV - Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na grande quantidade de entorpecentes apreendidos, assim como pelo fato de que o paciente já respondeu por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de entorpecentes, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demonstram que o paciente se dedicava às atividades criminosas (...) Agravo regimental desprovido". (STJ, AgRg no HC 604.121/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PRÁTICA ANTERIOR DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. A Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 3. Na hipótese, o pretendido redutor foi afastado com fundamento não só na quantidade e na diversidade do entorpecente apreendido mas também na anterior prática de ato infracional equivalente ao tráfico de drogas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ, AgRg no HC 588.716/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 28/08/2020).

"(...) - O ora paciente conta com condenação anterior à medida socioeducativa de internação, pela prática do ato infracional equiparado ao tráfico de entorpecentes. Dessa forma, sobeja essa razão, idônea nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, para afastar a redutora do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, pois atesta a dedicação do acusado à atividade criminosa (...) Habeas corpus não conhecido." (STJ, HC 481.232/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018).

Apesar de existir posicionamento no Supremo Tribunal Federal no sentido de que a utilização de atos infracionais não constitui fundamentação idônea para afastar a aplicação da figura do tráfico privilegiado, a questão não é pacífica e encontra divergência no âmbito das duas turmas da Suprema Corte, em conformidade com os julgados que cito abaixo:

"Agravo regimental no habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Pretendida aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Utilização da prática de atos infracionais para afastar a causa de diminuição. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido." (STF, HC 192147 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 19-04-2021 PUBLIC 20-04-2021).

"Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Utilização da prática de atos infracionais para

se afastar a causa de diminuição. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido." (STF, RHC 190434 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 12-11-2021 PUBLIC 16-11-2021).

"Habeas corpus. (...) Redutor. Tráfico privilegiado. Existência de ato infracional. (...)1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, "[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006" (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/10/14). (...) (STF, HC 195540, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 13-08-2021 PUBLIC 16-08-2021).

No mesmo sentido, confira-se: STF, HC 206922, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 24/09/2021, publicado em 27/09/2021.

Não havendo outras causas de modificação da pena, torno-a definitiva.

O valor do dia multa será no mínimo legal.

Crime de resistência - artigo 329 do Código Penal

Observando-se os elementos dos autos e aqueles norteadores previstos nos arts. 59 e 60, do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, em 02 (dois) meses de detenção.

Não há alterações na segunda fase, porque a circunstância atenuante não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, muito menos a menoridade, conforme o art. 65, inc. I do Código Penal.

Não havendo outras causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena acima fixada.

Por força do concurso material de infrações, porque o acusado, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes, com fundamento no artigo 69 do Código Penal, somo as reprimendas, chegando à pena final de 05 (cinco) anos de reclusão, bem como 02 (dois) meses de detenção, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A pena privativa de liberdade do crime apenado com reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado, sobretudo pela natureza e quantidade das drogas em discussão (240 porções de maconha, pesando 773 gramas, e 169 porções de cocaína, na forma de "crack", pesando no total 39,68 gramas), nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, sem a aplicação do redutor previsto em lei conforme acima mencionado.

Regime diverso do fechado para quem não faz jus ao redutor legal seria de extrema benevolência, por se tratar de crime assemelhado a hediondo.

Quanto ao delito apenado com detenção, o regime será o inicial aberto.

Inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por força da restrição imposta pelo art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como pela suspensão condicional da pena em função da vedação do art. 44, da Lei nº 11.343/2006.

No entanto, a partir do julgamento do HC 97.256/RS pelo STF, declarando incidentalmente a parcial inconstitucionalidade do § 4º do art. 33 e do art. 44, ambos da Lei n. 11.343/2006, o benefício da substituição da pena passou a ser concedido aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, desde que preenchidos os

requisitos insertos no art. 44 do Código Penal.

Não basta a primariedade para fazer jus à substituição, pois deve o juiz levar em conta, além da natureza e da quantidade da substância ou do produto, a personalidade do agente e a conduta social do agente.

Nesses termos, entendo que o comportamento do réu, desde a polícia, bem como em juízo, leva a crer que sua personalidade, no que tange à maturidade e a responsabilidade, torna inviável a conversão da pena em restritivas de direitos.

Com relação ao texto da Lei 12.736/2012, pondero óbice no texto completo do art.112 da LEP, que prevê, para a concessão de trânsito de um para outro regime, de vários outros aspectos, não somente o lapso temporal, como bom comportamento carcerário, por exemplo, situação que até agora não foi objeto de apuração.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar YURI GABRIEL CANDIDO DA SILVA, qualificado nos autos, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de pagamento de 500 (quinhentos e dez) dias-multa, no seu menor valor, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 329, "caput", do CP, na forma do art. 69, caput, do Código Penal (concurso material).

O réu não poderá apelar em liberdade, uma vez que permaneceu preso durante este processo e ainda persistem os fundamentos que determinaram a prisão, em especial, a necessidade de garantir a ordem pública, ante as nefastas consequências do tráfico de drogas para a sociedade em geral e a probabilidade concreta de solto, voltar a praticar o comércio espúrio de drogas, devendo ser recomendado na prisão em que se encontra recolhido.

A detração penal será analisada em sede de execução, devendo se verificar a conduta carcerária do réu e os demais requisitos do processo de execução.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual.

Defiro a incineração da substância entorpecente apreendida com as cautelas de praxe.

Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Limeira, 27 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA